

R.G. n. 30971/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 30971 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2017 vertente

TRA

Parte_1 , *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* , **nella
qualità di eredi della de cuius** *Persona_1* , rappresentati e difesi
dall'avv. Antonino De Luca ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma alla
via Giorgio Scalia 6, come da procure separate, allegate alla comparsa di
intervento depositata il 27.7.2021.

Attori

E

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia
Camporeale, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa

di costituzione ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma alla via Pilo Albertelli 1

Convenuta

Conclusioni: come da note scritte ex art.87 co 3 DL18/20

Avente ad oggetto: responsabilità sanitaria

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 4.5.2017, la signora *Persona_1* ha convenuto in giudizio l' *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, per sentirla condannare, all'integrale risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza del ricovero presso lo stesso Policlinico il 29.5.2014 per un trauma e dimessa il 3.7.2014, ivi contraendo l'infezione microbica da Klebsiella dell'apparato oculare "endoftalmite" che aveva causato la cecità dell'occhio sinistro, sano al momento del ricovero in ospedale.

Chiedeva che il Tribunale : 1) accertasse e dichiarasse che "l'infezione microbica da Klebsiella dell'apparato oculare "endoftalmite" che ha causato la cecità dell'occhio sinistro, sano al momento del ricovero in ospedale, è stata contratta dalla signora *Per_1* in costanza di ricovero ed è quindi di natura nosocomiale; 2) accertasse e dichiarasse che, "nel prestare la propria opera i sanitari del *Controparte_1* hanno posto in essere un comportamento professionale colposo, cagionando alla Signora *Per_1* un danno iatrogeno, in rapporto causale sia con la prestazione sanitaria dal carattere sostanzialmente ordinario, sia con l'infezione di sicura origine ospedaliera non tempestivamente trattata; e valutata l'entità del danno nella misura complessiva del 35% comprensivo del danno biologico per l'effetto. -condannare l' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale risarcimento del danno biologico riportato dall'attrice che, comprensivo del danno psichico ed estetico, si quantifica in complessivi euro 103.193,98 o in quella

cifra che il Giudice vorrà determinare con criterio equitativo nella liquidazione del danno iatrogeno, con valore differenziato del punto di invalidità, aumentandone il valore monetario o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio l' *Controparte_1* contestando in toto la domanda attrice, chiedendone l'integrale rigetto e comunque chiedendo l'ammissione di CTU onde accertare le cause dell'infezione contratta dall'attrice e l'entità dei danni dalla stessa subiti.

Esaurita la fase istruttoria con il deposito di CTU medico-legale, il tentativo di mediazione avente esito negativo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.

Va osservato che con atto di intervento depositato il 27.7.2021, i sigg.ri *Parte_1* , *Parte_2* , *Pt_3* e *Pt_5* , premesso che la sig. *Persona_1* era deceduta il 31.1.2020, come da atto di morte che producevano, intervenivano nel giudizio IN QUALITA' di EREDI, riportandosi integralmente all'atto di citazione ed agendo, si desume implicitamente, iure successionis.

Ebbene, parte convenuta non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla qualità di eredi degli interventori, difendendosi ampiamente nel merito e tale condotta, oltre ad essere incompatibile con la suddetta eccezione, da un punto di vista strettamente giuridico, andrebbe considerata come non contestazione ex art.115 c.p.c. della qualità di eredi degli interventori.

Invero, la sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n.2951/16, se da un lato ha affermato il principio generale che la titolarità attiva va provata dall'attore ed è rilevabile d'ufficio, ha anche chiarito che l'onere di allegazione e prova da parte dell'attore della titolarità attiva, si considera comunque assolto in due casi: 1) quando

il convenuto svolge difese incompatibili con la carenza di titolarità attiva dell'attore;
2) quando il convenuto non contesta detta titolarità (art.115 c.p.c.), salva sempre la facoltà del giudice di ritenerla non provata sulla base di diverse prove.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16904/18, ha chiarito, che la sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 2951/16, relativamente alla rilevabilità d'ufficio della carenza della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, aveva specificato che il giudice chiamato a rilevare l'insussistenza di detta condizione dell'azione, è tenuto a fare una verifica della sussistenza o meno della stessa, sulla base delle prove acquisite al processo, ovvero di quelle dirette (documentali o non) e di quelle indirette, ovvero desumibili dal contegno delle parti, tra cui va ritenuto compreso il comportamento del convenuto, incompatibile con la negazione della titolarità attiva dell'attore.

Sul punto merita però di essere riportato il principio di diritto espresso più di recente dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9439/22: *“il convenuto, a fronte di un'allegazione da parte dell'attore chiara ed articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità, e se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c. E' pertanto generica e come tale priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto eccepisca tout court l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione”*.

Tuttavia, il caso di specie è diverso da quello cui si riferiscono le suddette sentenze, sotto due profili: uno di natura processuale ed uno di natura sostanziale.

Invero il giudice non può, nell'ambito del suo potere-dovere di rilievo d'ufficio della insussistenza della titolarità attiva, prescindere dal valutare i fatti che devono ritenersi allegati e provati ex art.115 c.p.c., sempre che l'allegazione sia chiara e articolata in punto di fatto (Cass. n. 9439/22).

Ebbene, nel caso di specie, gli interventori non hanno né dedotto, né allegato alcunché e tanto meno fornito un'allegazione chiara e articolata in punto di fatto : non hanno dedotto e allegato chi siano, ovvero non hanno nemmeno specificato se sono i figli della de cuius, i nipoti ecc..., né se sono gli unici eredi.

In sostanza non avendo dedotto nulla, né allegato quanto meno lo stato di famiglia, per cui si ignora completamente il loro rapporto di parentela con la de cuius, sicché il giudice, in mancanza assoluta di allegazione, non può applicare il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.

Ma vi è di più.

Nel caso di specie, si verte in tema di successione nel processo ex art.110 c.p.c.

Qui non siamo in presenza della legittimazione attiva, intesa non come titolarità del rapporto dedotto in giudizio e dunque di una questione di merito cui può applicarsi l'art.115 c.p.c.

Nella fattispecie in esame, siamo in presenza di una questione di legittimatio ad processum, rilevabile d'ufficio al di là della non contestazione.

Sul punto la Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 2951/16 ha precisato che: “**chi interviene** nella qualità di erede deve provare la sua successione nel processo e non rileva la mancata contestazione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio”.

Tale principio è stato ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 12065/14 che ha affermato: “**colui che interviene** in un giudizio pendente tra altre parti deve fornire la prova ex art.2697 c.c. oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede”.

Da ultimo, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11276/18, si è così espressa: *Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di*

*erede di colui che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite ex art.372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza della prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad agire ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (Cass. 1943/11; 2046/13; 4116/16; 15414/17). Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che colui che assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, **intervenga** in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione e proponga impugnazione, deve fornire la prova ai sensi dell'art.2697 c.c. anche della sua qualità di erede”.*

Come già detto innanzi, si ribadisce che nel caso di specie, non siamo in presenza di una questione di merito e comunque nemmeno in astratto potrebbe applicarsi il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., perché non si verte in tema di “fatti specificamente dedotti ed allegati”, sicchè non sorge nemmeno un onere di contestazione a carico della controparte.

Ciò premesso, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimatio ad processum degli interventori.

Rilevato che l'ammissione al gratuito patrocinio si riferisce solo alla de cuius, che peraltro risale al 2017 e non risulta integrata ad oggi, per provare la persistenza almeno sino al decesso delle condizioni richieste per usufruire del beneficio; rilevato altresì che non risulta presentata istanza di ammissione al gratuito patrocinio da parte degli interventori e che questi ultimi non hanno provato la loro qualità di eredi, va revocata l'ammissione al gratuito patrocinio deliberata il 13.3.2017 in favore della de cuius

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e queste ultime sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 scaglione da 52.000,00 a 260.000,00.

Quanto alla CTU, non avendo rinvenuto in atti il decreto di liquidazione, si liquida in favore di ciascun CTU, la somma di euro 2.400,00 a titolo di onorario, detratto l'acconto se già versato.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Roma, XIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* , *Parte_3* , [...] *Parte_2* e *Parte_4* , nei confronti del *Controparte_1* , così provvede;

- 1) Dichiara inammissibile la domanda;
- 2) Condanna *Parte_1* , *Pt_3* , *Parte_2* e *Pt_4* , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano in euro 8.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso generale nella misura del 15%, nonché al pagamento in solido delle spese di CTU, che si liquidano per ciascun CTU in euro 2.400 per onorario oltre iva se dovuta e quindi a favore rispettivamente del CTU dott.ssa *Persona_2* e del CTU dott. *Persona_3* .

Roma 26.4.2023

Il Giudice

Dott.ssa Ornella Baiocco